

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5724/2554

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายสุภีหรือเตี้ย ดวงหาคลัง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 277 (เดิม), มาตรา 277 (ใหม่), มาตรา 279 วรรคแรก

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

การกระทำชำเราตาม ป.อ. มาตรา 277 เดิม คือ การร่วมประเวณีหรือการร่วมเพศ โดยต้องเป็นการกระทำถึงขั้นใช้อวัยวะเพศของชายใส่ล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิง เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติม ป.อ. ตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2550 มาตรา 3 ป.อ. มาตรา 277 วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่บัญญัติว่า "การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำ กระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น" เห็นได้ว่า การแก้ไขดังกล่าวเป็นการขยายขอบเขตของการกระทำชำเราให้กว้างขึ้นเฉพาะในส่วนเพศของผู้กระทำกับเพศของผู้ได้รับการกระทำ อวัยวะและสิ่งที่ใช้กระทำกับอวัยวะที่ได้รับการกระทำกับเจตนาพิเศษในการกระทำ โดยจากเดิมเพศชายกระทำกับเพศหญิงเท่านั้น เป็นเพศใดกระทำกับเพศใดก็ได้ จากเดิมใช้อวัยวะเพศชายกระทำกับอวัยวะเพศหญิงเท่านั้น เป็นใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำเพศใดก็ได้กระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่นเพศใดก็ได้ หรือใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศ หรือทวารหนักของผู้อื่นเพศใดก็ได้ แล้วแต่กรณี และต้องกระทำโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ อันเป็นการ

ทำให้บุคคลทุกเพศได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกัน แต่ในส่วนลักษณะของการกระทำนั้น มิได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงยังต้องเป็นการกระทำถึงขั้นใช้อวัยวะเพศหรือสิ่งอื่นใดใส่ล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะต่างๆ ดังกล่าวอันเป็นอวัยวะที่เป็นช่องหรือรูเปิดของร่างกาย ดังนั้น การที่จำเลยใช้อวัยวะเพศบุกรุกบริเวณอวัยวะเพศของผู้เสียหายอันเป็นการสัมผัสภายนอก ไม่มีการล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศผู้เสียหาย จึงยังไม่ใช่ความผิดฐานกระทำชำเราตาม ป.อ. มาตรา 277 แต่เป็นการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศ อันเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคแรก การกระทำชำเรารวมถึงการกระทำอนาจารอยู่ในตัว ศาลจึงลงโทษจำเลยฐานกระทำอนาจารตามที่พิจารณาได้ความ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 277

จำเลยให้การปฏิเสธ

ก่อนเริ่มสืบพยาน เด็กหญิง ธ. ผู้เสียหาย โดยนางจันจิรา ผู้แทนโดยชอบธรรม ยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวน 80,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก จำคุก 2 ปี และให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 10,000 บาท ข้อยาและคำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยที่ใช้อวัยวะเพศของจำเลย ฎูโถอวัยวะเพศของผู้เสียหายเป็นการกระทำความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า ตามวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยเอาอวัยวะเพศของจำเลย ฎูโถบริเวณด้านนอก อวัยวะเพศของผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุสี่ปีเศษ แพทย์ตรวจร่างกายผู้เสียหาย ไม่พบบาดแผลฉีกขาดของเยื่อพรหมจารี ไม่พบหลักฐานของน้ำอสุจิจากบริเวณ ปากช่องคลอด และมีความเห็นว่าตรวจไม่พบหลักฐานของการร่วมประเวณีผ่านเข้าไปในช่องคลอด โจทก์ฎีกาว่า การกระทำชำเราอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่า เป็นการร่วมประเวณี หรือการร่วมเพศอันเป็นการกระทำในลักษณะสอดหรือล้วงล้าเข้าไปเท่านั้น เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสองที่แก้ไขใหม่ มีความหมายรวมถึงการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำ กระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำสอดหรือล้วงล้าเข้าไปในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่นนั้นแต่อย่างใด เพียงแต่การกระทำความผิดดังกล่าว ต้องเป็นการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำอันเป็นเจตนาพิเศษนั้น เห็นว่า การกระทำชำเราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 เดิม คือ การร่วมประเวณีหรือการร่วมเพศ โดยต้องเป็นการกระทำถึงขั้นใช้อวัยวะเพศของชายใส่ล้วงล้าเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิง เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2550 มาตรา 3

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่บัญญัติว่า "การกระทำ
ซ้ำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดย
การใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำ กระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้
อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น" เห็นได้ว่า การ
แก้ไขดังกล่าวเป็นการขยายขอบเขตของการกระทำซ้ำเราให้กว้างขึ้นเฉพาะในส่วน
เพศของผู้กระทำกับเพศของผู้ได้รับการกระทำ อวัยวะและสิ่งที่ใช้กระทำกับอวัยวะที่
ได้รับการกระทำกับเจตนาพิเศษในการกระทำ โดยจากเดิมเพศชายกระทำกับเพศ
หญิงเท่านั้น เป็นเพศใดกระทำกับเพศใดก็ได้ จากเดิมใช้อวัยวะเพศชายกระทำกับ
อวัยวะเพศหญิงเท่านั้น เป็นใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำเพศใดก็ได้กระทำกับอวัยวะ
เพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่นเพศใดก็ได้ หรือใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะ
เพศ หรือทวารหนักของผู้อื่นเพศใดก็ได้ แล้วแต่กรณี และต้องกระทำโดยมีเจตนา
พิเศษเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ อันเป็นการทำให้บุคคลทุกเพศได้รับความ
คุ้มครองเท่าเทียมกัน แต่ในส่วนลักษณะของการกระทำนั้น มิได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงยังต้องเป็นการกระทำถึงขั้นใช้อวัยวะเพศหรือสิ่งอื่นใดใส่
ล้วงล้ำเข้าไปในอวัยวะต่างๆ อันเป็นอวัยวะที่เป็นช่องหรือรูเปิดของร่างกาย ดังนั้น
การที่จำเลยใช้อวัยวะเพศถูไถบริเวณอวัยวะเพศของผู้เสียหายอันเป็นการสัมผัส
ภายนอก ไม่มีการล้วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศผู้เสียหาย จึงยังไม่เป็นความผิดฐาน
กระทำซ้ำเราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 แต่เป็นการกระทำที่ไม่สมควร
ในทางเพศ อันเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
279 วรรคแรก การกระทำซ้ำเราวมถึงการกระทำอนาจารอยู่ในตัว ศาลจึงลงโทษ
จำเลยฐานกระทำอนาจารตามที่พิจารณาได้ความได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษานั้น ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

(ชีพ จุลมนต์-วีระวัฒน์ ปวราจารย์-โสฬส สุวรรณเนตร์)

ศาลอาญาธนบุรี - นายสมชัย สายเชื้อ

ศาลอุทธรณ์ - นายดุสิต จิมพลีย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ3932/2551

ต้น

หมายเหตุ